

1500015-56.2021.8.26.0648

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: VINICIUS NUNES ABBUD

Comarca: Urupês

Foro: Foro de Urupês

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 23/06/2022

... pelos tribunais pátrios:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Urupês

Foro de Urupês

Vara Única

Praça Jardim Bela Vista, s/n, Urupes - SP - cep 15850-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500015-56.2021.8.26.0648 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500015-56.2021.8.26.0648

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CRISTIANO ANDRADE NUNES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VINICIUS NUNES ABBUD

Processo nº 1500015-56.2021.8.26.0648

Vistos.

CRISTIANO ANDRADE NUNES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, porque no dia 17 de outubro de 2020, por volta das 18 horas, na Vicinal Abramo Buratto, no município de Sales, o denunciado teria trazido consigo uma porção de maconha, com peso aproximado de 23 gramas, o fazendo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com intuito de fornecer ou entregar as substâncias ilícitas ao consumo de terceiros.

A denúncia teve por base o inquérito policial e foi recebida no dia 05 de maio de 2021 (fl. 41).

O réu foi citado (fl. 63).

Ao longo da instrução, foram ouvidas as testemunhas tempestivamente arroladas. O réu não compareceu em juízo para ser interrogado, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação, nos termos da denúncia, por considerar provadas autoria e materialidade. A defesa, por sua vez (fls.

104/110), pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, pela desclassificação da imputação para o delito previsto no artigo 28, da Lei 11.343/06 e pela aplicação ao caso da causa de diminuição de pena veiculada no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

É o relatório. Fundamento e DECIDO.

Processo em ordem, que se desenvolveu em obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Não há nulidade a ser declarada ou vício a ser sanado.

Quanto ao mérito, iniciando as necessárias perquirições pela imputação referente à prática do tráfico, observo, nesse particular, que a materialidade delitiva foi demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 01/03), auto de exibição e apreensão (fl. 10), laudo pericial (fls. 12/14), bem como pela prova oral colhida em juízo. A autoria é certa e indubitosa.

A testemunha Guilherme Garbuio, policial militar, contou que estava em patrulhamento, e já tinham conhecimento sobre o envolvimento do acusado com o tráfico de drogas. Quando Cristiano, João e Lucas avistaram a equipe policial, saíram com as bicicletas sentido à Vicinal Abramo Burato, que liga Sales à praia do Cervinho. Diante da atitude suspeita, realizaram a abordagem e encontraram o entorpecente na posse de Cristiano. Em entrevista pessoal, Cristiano afirmou que estavam indo ao Cervinho para consumir a droga, porém João e Lucas disseram que estavam indo ao cervinho nadar. Esclareceu que as denúncias chegavam via 181, bem como de populares que procuravam os policiais diretamente na viatura, o que é comum acontecer na cidade de Sales. Relatou que, em 12 de março de 2021, o acusado utilizou suas redes sociais para proferir as seguintes ofensas: "Garbuio pau no cu do caralho; policial de bosta; arrombado"; "Quero que você, que é da família do Garbuio se foda"; "Foco no progresso, porque verme é verme, rasteja no chão, to fazendo o corre mesmo, não gostou processa eu, narigudo do caralho"; "É tudo três". Em pesquisa, o declarante descobriu que a expressão "É tudo três" se refere ao terceiro comando puro, facção criminosa. Posteriormente, em 11 de março de 2022, o acusado fez outra publicação falando "policial narigudo, tentando me forjar" e disse que depois daria mais notícias aos seus seguidores.

A testemunha Júlio César de Oliveira, policial militar, relatou que estava em patrulhamento junto com o cabo Garbuio, no município de Sales, quando avistaram três indivíduos em duas bicicletas, a uma distância de 2 quarteirões. Quando os indivíduos notaram a presença da viatura, viraram à esquerda como se estivessem empreendendo fuga. O policial Garbuio reconheceu Cristiano e decidiram realizar a abordagem, uma vez que existiam diversas denúncias indicando o seu envolvimento com o tráfico de drogas. Realizada a abordagem, em revista pessoal, com Cristiano foram localizados os entorpecentes. Informou que no celular de um dos meninos abordados havia um grupo para monitorar a movimentação da viatura de Sales. Esclareceu que o próprio indivíduo afirmou ao policial Garbuio sobre a existência do referido grupo em seu telefone celular.

Nesse quadro, na esteira de entendimento corrente, cumpre enfatizar que o depoimento de policial, autoridade investida de poder estatal, goza de inegável valia, tratando-se de prova apta a amparar a condenação, sobretudo no presente caso, em que não paira sobre as testemunhas, de forma fundada e concreta, qualquer suspeita de parcialidade ou inidoneidade.

Evidentemente, afigurar-se-ia injusto, e até ilógico, encarregar a polícia da segurança pública e depois desconsiderar os depoimentos que seus agentes venham a prestar, dando conta de suas perigosas e respeitáveis atividades funcionais.

Nesse sentido:

Tráfico de entorpecentes – Materialidade e autoria comprovadas por depoimentos de policiais cujo conteúdo é harmônico com o conjunto probatório – Validade No que concerne ao valor dos depoimentos prestados pelos policiais, os tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis quaisquer análises preconceituosas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. As declarações prestadas pelos agentes que efetuaram a prisão do acusado são válidas e têm o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza nos autos; por gozarem de fé pública, suas versões devem ser reputadas fidedignas, até que se prove o contrário. (...) (TJSP; Apelação Criminal 0094524-48.2014.8.26.0050; Relator (a): Grassi

Neto; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 7ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/10/2016; Data de Registro: 01/11/2016);

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM VASTO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. IMPOSSIBILIDADE DE IMERSÃO VERTICAL NA MOLDURA FÁTICA E PROBATÓRIA DELINEADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM NA VIA PROCESSUAL ELEITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO DEFINITIVA. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O BENEFÍCIO. MATÉRIA PACIFICADA NO ERESP 1.431.091/SP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS DE RECLUSÃO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) A conclusão obtida pelas instâncias de origem sobre a condenação no referido delito foi lastreada em vasto acervo probatório, sendo que o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. A incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. A Terceira Seção pacificou entendimento no sentido de que é possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formação da convicção de que o Réu se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06 (ERESP 1.431.091/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 1º/2/2017). (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

O réu, por sua vez, não compareceu em juízo para narrar a sua versão dos fatos. Ouvido em solo policial, o réu confessou a propriedade da droga, porém justificou que seria destinada para o próprio consumo.

Logo, não há dúvidas que o réu fora efetivamente surpreendido trazendo consigo uma porção grande de maconha, com peso aproximado de 23 gramas, conduta que se amolda ao tipo imputado.

Conforme destacou o policial Garbuio, haviam diversas denúncias indicando a prática do tráfico de drogas pelo acusado. Ademais, ao notarem a presença da viatura, os indivíduos tentaram empreender fuga, fato que motivou a abordagem.

Vale salientar, como bem observou o D. Promotor de Justiça, que a quantidade de drogas apreendida na posse do réu seria suficiente para confeccionar mais de 20 cigarros, de modo que não é crível que estivesse trafegando em via pública com tamanha quantidade apenas para o consumo próprio.

Nesse particular, destaco que a diligência policial que culminou com o ajuizamento desta ação penal não se deu ao acaso, decorrendo de inúmeras denúncias alusivas à prática do tráfico pelo acusado, elementos de prova indiciários confirmados pela apreensão de droga em sua posse.

Encontrando-se bem elucidado que a propriedade de todo o entorpecente apreendido realmente deve ser atribuída ao denunciado, o intuito mercantil e, por conseguinte, a traficância, exsurtem evidentes, à luz dos critérios elencados no artigo 28, § 2º, da Lei de Drogas.

Além dos relatos policiais registrando a existência de diversas denúncias anônimas sobre a prática do tráfico pelo réu, observo que a quantidade de substância ilícita arrestada, aproximadamente 23 gramas de maconha, em muito supera aquilo que normalmente se encontra na posse de um simples usuário.

De se ressaltar que eventual condição de usuário do acusado, por si, não tem o condão de afastar as ilações ora tomadas, eis que as particularidades da ação criminosa e as circunstâncias da prisão justificam a responsabilização pelo crime de tráfico.

Aliás, a rotina forense demonstra que muitos usuários acabam praticando o comércio

espúrio para viabilizar a manutenção do próprio consumo, devendo responder pela conduta mais grave, como vem pacificamente entendendo a Egrégia Corte Bandeirante: "A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do traficante, mormente na hipótese vertente, em que ambas se mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior gravidade" (TJSP RJTJSP, 101/498);

"Pouco importa, de resto, se o apelante é usuário ou não, pois viciado, quando trafica, deve responder pelo crime mais grave, que se consuma com o mero porte da substância entorpecente, para o fim de entrega a terceiros, independentemente da ocorrência de qualquer ato de comércio." (TJSP - AC 896.821.3/8-00, Rel. René Ricupero J. 30.11.2006).

O fato de não ter sido o increpado flagrado efetuando, propriamente, a comercialização de entorpecente não compromete a materialização do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Como se sabe, o tipo penal em análise constitui delito de ação múltipla ou conteúdo variado, perfazendo-se com a realização de qualquer dos verbos nele descrito, os quais não se encontram submetidos a regime cumulativo.

Atente-se para o quanto já decidido pelos tribunais pátrios:

"Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do agente." (RT 584/347).

Encerrando a tipificação, sublinho que a causa de diminuição de pena trazida pelo § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, não se mostra aplicável na espécie. No caso dos autos a prova oral demonstrou de forma segura e coesa que o réu dedicava-se às atividades criminosas, uma vez que os policiais ouvidos em juízo afirmaram a existência de diversas denúncias indicando a prática do tráfico de drogas pelo denunciado. Assim, não preenchidos os requisitos legais, inviável a redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas no caso dos autos.

Desse modo, apreciadas as teses levantadas por acusação e defesa, não incidindo causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a procedência dos pedidos formulados, com a condenação do acusado nas sanções contidas no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Passo, pois, a dosar a pena, considerando o critério trifásico trazido pelo artigo 68, do Código Penal.

Para fixação da pena-base, devem ser levadas em consideração as circunstâncias judiciais, tanto as genéricas, veiculadas pelo artigo 59, do Código Penal, como as específicas para o delito em análise, insculpidas no artigo 42, da Lei de Tóxicos. Nesse mister, inobstante primário, o réu tinha em depósito e trazia consigo considerável quantidade de entorpecente, a qual seria suficiente para alimentar o vício de um grande número de usuários, conjuntura que imprime elevado grau de censurabilidade à sua conduta perpetrada. Desse modo, pela quantidade da droga traficada, fixo a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, em cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Não havendo fator a ser considerado na segunda fase da dosimetria, resta aqui inalterada a pena.

Nada há a ser considerado na terceira etapa, valendo registrar que a prática do tráfico de forma habitual, conforme demonstrado pela prova oral colhida, afasta a incidência da minorante prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, pois o reconhecimento do privilégio exige, dentre outros requisitos, que o agente não se dedique às atividades criminosas.

Inexistindo nos autos elementos que forneçam parâmetros seguros para a aferição da condição econômica do réu, fica o valor do dia-multa fixado no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, nos termos do artigo 43 da Lei 11.343/2006.

Sem confrontar posicionamento recentemente adotado pelo C. STF (habeas corpus nº 97.256/RS, cujos efeitos foram ampliados pela Resolução nº 5/2012, do Senado

Federal), diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis, máxime as previstas na legislação especial, o que, inclusive, deu azo à majoração da pena-base e do total da pena aplicada, reputo inviável, na espécie, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos ou a substituição condicional da pena, considerada a inteligência dos artigos 44, I e III e 77, caput e II, ambos do Código Penal.

Aqui, releva repisar que o réu foi surpreendido com grande quantidade de maconha, a qual seria suficiente para atingir inúmeros usuários.

Referida conduta, legalmente definida como hedionda, desencadeia catastróficas consequências sociais, já que a disseminação das drogas, além de representar grande prejuízo individual ao consumidor, dá ensejo, inegavelmente, à ocorrência de diversos outros crimes, especialmente os patrimoniais, alarmando a população.

Não se mostra exagerado afirmar que o traficante, buscando lucro fácil, explora a degradação humana, aproveitando-se da fissura do usuário que, como sabido, não mede esforços para suprir a necessidade de acesso ao "produto" oferecido.

O "freguês", destarte, é presa fácil para o mercador do tóxico, resultando dessa desigual e injusta interação problemas de saúde e segurança públicas de dimensões incomensuráveis.

Nesse cenário, a ação perpetrada, diante de sua gravidade concreta, merece resposta penal enérgica e exemplar, sendo certo que a aplicação de simples pena alternativa, ou a suspensão da pena, geraria na sociedade grande sensação de insegurança, além de criar na própria ré sentimento de impunidade, o que o estimularia a prosseguir violando a lei penal.

O delito imputado ao acusado é equiparado pela Lei aos crimes hediondos e, assim, nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a nova redação dada pela Lei nº 11.464/07, deverá a pena privativa de liberdade imposta ser cumprida em REGIME INICIAL FECHADO, observando-se a nova fração para progressão estabelecida na hipótese.

Em observância ao entendimento esposado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do habeas corpus n.º 111.840 (Rel. Min. Ministro Dias Toffoli, j. 27.6.2012), registre-se que, diante das ilações tecidas nos parágrafos supra, regime diverso não se mostraria suficiente para a punição da conduta, reiterada a subsistência de circunstâncias judiciais especiais desfavoráveis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, o fazendo para condenar CRISTIANO ANDRADE NUNES, portador da cédula de identidade R.G. nº 49.140.620/SP, filho de Cristiano Lucrecio Nunes e Sheila Ferreira de Andrade, natural de Aimores-MG, devidamente qualificado nos autos (fl. 02), como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de pena de cinco anos e dez meses e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

A multa deverá ser paga em dez dias, a contar do trânsito em julgado, nos termos do artigo 50 do Código Penal, observada a disposição constante do artigo 49, § 2º, do mesmo Codex.

Embora o réu tenha respondido o processo solto, não concedo o direito de recorrer em liberdade. No caso dos autos, o policial Garbuio narrou que o acusado publicou em suas redes sociais xingamentos e ofensas direcionadas tanto ao próprio policial quanto à sua família, fatos comprovados pelos vídeos (link fl. 96). Tal fato demonstra o desprezo pelo sentenciado às autoridades constituídas, além de evidenciar, como dito e gesticulado de forma altiva pelo acusado ("é tudo três"), o seu envolvimento com o crime organizado.

Além disso, o próprio réu mencionou que "(...) to fazendo o corre mesmo, não gostou processa eu, narigudo do caralho". Diante de tais fatos, é evidente o perigo gerado pela liberdade do autuado. Portanto, a segregação cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública a fim de proteger a integridade física tanto da testemunha, quanto de seus familiares, bem como para evitar a reiteração delitiva por parte do sentenciado.

Ademais, o sentenciado demonstrou completo desprezo pelo próprio processo, conforme consta dos vídeos já mencionados e ratificado pela ausência em audiência de instrução e julgamento, de modo que a prisão preventiva também mostra-se necessária para assegurar a aplicação da lei penal.

Desse modo, considerando que as medidas cautelares distintas da prisão mostram-se insuficientes ao caso dos autos, decreto a prisão preventiva do sentenciado. Expeça-se mandado de prisão.

Anoto que o I. Membro do Ministério Público pleiteou a fixação de medidas cautelares distintas da prisão, com fundamento no art. 319, incisos I, IV e V, do CPP. Desse modo, não há que se falar em atuação de ofício por parte deste Magistrado, pois havendo provocação pelo órgão Ministerial, cabe ao Juiz escolher qual medida cautelar pessoal melhor se ajusta ao caso concreto.

Sobre o tema já decidiu o C.STJ:

Se o Ministério Público requer a conversão do flagrante em cautelares diversas, o juiz pode decretar a prisão preventiva, não havendo que se falar em atuação de ofício. STJ, RHC 145.225, Rel. Min. Rogerio Schietti, 6ª Turma, j. 12.02.2022, Informativo 725.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição do entorpecente apreendido, na forma do artigo 50, §§ 3º, 4º e 5º, da Lei 11.343/06. Não incidem os efeitos da condenação previstos no artigo 92, do Código Penal, dada a natureza da infração penal praticada.

Deixo de adotar a providência determinada pelo artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, porque o delito praticado não possui vítima certa.

Custas na forma da Lei (artigo 4º, § 9º, da Lei Estadual 11.608/03), ficando concedido ao réu o benefício da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

Após o trânsito em julgado, proceda-se na forma do artigo 63, § 4º, da Lei 11.343/06, com relação aos bens e valores declarados perdidos em favor da União, oficie-se para suspensão dos direitos políticos do acusado enquanto perdurarem os efeitos da condenação, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal e expeça-se o necessário para o cumprimento definitivo das penas impostas, realizando-se as anotações e comunicações de praxe, tudo de acordo com as NSCGJ (notadamente com os artigos 393 a 400, do capítulo IV, seção XI, subseção V, Tomo I; do artigo 468, do capítulo IV, seção XX, subseção I, Tomo I; e do artigo 479, do capítulo IV, seção X, subseção III, Tomo I).

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º das Normas de Serviço da E. Corregedoria Geral de Justiça.

Cumpra-se e Intimem-se.

Urupes, 23 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA